

1502089-53.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.

LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502089-53.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502089-53.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO RODRIGUES DE FREITAS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ANDERSON MARCELO LEITE GARCIA e CLÁUDIO RODRIGUES DE FREITAS foram denunciados por incursão no caput do art. 33 c.c. inciso IV do artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 15h40min, na Travessa Ubajara, 10, Jardim Rosina, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, envolvendo o adolescente L.R.M., com dezesseis anos de idade, traziam consigo e expunham à venda, para entrega a consumo de terceiros as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 29-30) e laudo de constatação (fls. 44-6), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, afastando-se somente a causa de aumento prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/06, enquanto a Defesa, em preliminar, insiste no cabimento da proposta de acordo de não persecução penal, bem como suscita a ilicitude da prova. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, ou, ao menos, a desclassificação da conduta de Cláudio para o crime previsto no art. 37 da Lei de Drogas, a fixação das penas no patamar mínimo, reconhecendo-se a menoridade relativa do réu Anderson e o tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento do inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

De partida, não há nulidade a ser reconhecida.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls. 129-33 e 229-34).

Também não há ilicitude na prova produzida.

A abordagem realizada pelos guardas municipais, no caso concreto, encontra respaldo no art. 5º da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), o qual regulamentou o § 8º do art. 144 da Constituição Federal e permite o patrulhamento preventivo a fim de "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social" (inciso IV) e "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário" (inciso XIV).

No caso dos autos, durante patrulhamento pelo local, visando a proteção da população local, os agentes municipais depararam-se com a situação flagrancial.

Não fosse suficiente, o crime de tráfico de drogas é permanente, de forma que, enquanto atuavam juntos para o narcotráfico, um deles vendendo drogas e o outro como olheiro, os investigados encontravam-se em flagrante delito.

Destaca-se, também, a ausência de qualquer irregularidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, diante da autorização prevista no art. 301 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, posicionou-se o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Alegada obtenção de provas por meios ilícitos, posto colhidas por guardas municipais. Impossibilidade. Nulidade não verificada. Pedido de absolvição. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Improcedência. [...] Não se vislumbra, in casu, a alegada obtenção das provas por meios ilícitos, porquanto não só os guardas municipais podem efetuar a prisão em flagrante, como qualquer um do povo pode fazê-lo. É o teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Ademais, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante

delito encontravam-se atuantes nos estritos termos dispostos pela Lei 13.022/2014 que regulamentou a competência atribuída à Corporação pelo artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Com a edição de referida Lei, a guarda municipal, no seu território, pode exercer a polícia ostensiva e auxiliar as forças estaduais e federais na segurança pública. Particularmente, no âmbito do flagrante, destaca-se o artigo 5º, inciso XIV, da Lei 13.022/2014. Embora o preceituado neste artigo ultrapasse os limites previstos no artigo 144, § 8º, da CF, entendemos constitucional a previsão. Afinal, tudo o que se relaciona com o munícipe não deixa de ter relação com a tutela dos bens, serviços e instalações do Município onde reside. Ademais, deixou-se cláusula aberta ao final do parágrafo, "conforme dispuser a lei". Diante disso, a guarda municipal tem hoje, dentro dos limites municipais, o mesmo poder da Polícia Militar. [...]" (TJ/SP, Revisão Criminal nº 2017191-29.2020.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme De Souza Nucci, Data do julgamento: 13/07/2020, Data de publicação: 13/07/2020 - grifo nosso).

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Preliminar de nulidade Alegação de incompetência dos guardas municipais para efetuar a prisão em flagrante Descabimento Réu que estava em atitude suspeita Situação de flagrância Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Preliminar rejeitada MÉRITO Pleito de desclassificação Impossibilidade Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas nos autos Desnecessidade de se surpreender o agente em atos de comercialização Crime de conteúdo variado Condenação mantida PENA Quantidade e variedade de drogas a inviabilizar a aplicação, na fração máxima, do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 Abrandamento do regime prisional Desacolhimento, por maioria Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJ/SP, Apl. Criminal nº 0000508-07.2016.8.26.0544, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 27/06/2017, Data de publicação: 03/07/2017).

No mesmo sentido, há julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Sem razão a defesa também no ponto em que afirma haverem as guardas municipais exorbitado os limites do patrulhamento preventivo, ao agirem como polícia ostensiva. No caso, não se está a reconhecer o policiamento ostensivo das guardas municipais, mas sim a atribuição de funções essenciais à proteção da população local, bem como de bens, serviços e instalações. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda dos sobreditos bens jurídicos, o agente municipal se depare com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Além disso, a Lei n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevê, expressamente, como princípio mínimo de atuação das guardas municipais, o patrulhamento preventivo (art. 3º, III) e, não obstante dispositivos da referida legislação sejam objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.156, certo é que, até o momento, não houve nenhuma decisão por parte da Corte Suprema, de maneira que a lei em questão continua em pleno vigor no ordenamento jurídico pátrio. Finalmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades (v. g., AP n. 611/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 10/12/2014). Válida, portanto, foi a atuação das guardas municipais e, por conseguinte, a apreensão de substâncias entorpecentes por elas levada a efeito após

a realização de revista pessoal no acusado." (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.660 - SP (2017/0324006-0), Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicado em 17/02/2020 - grifo nosso).

"[...] Pois bem, do excerto transcrito verifica-se que o acórdão impugnado não destoia da jurisprudência desta Corte, que entende que a busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente. (AgRg no AREsp n. 1.565.524/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 12/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt no AREsp n. 950.569/MS, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/02/2017; e HC n. 525.772/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/10/2019. [...]." (STJ, HC 557934, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Publicado em 17/04/2020).

Superados, assim, os questionamentos preliminares.

No mérito, procede em parte a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 03-8), auto de exibição e apreensão (fls. 29-30), laudo de constatação (fls. 44-6), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 119-21), laudo da bolsa apreendida (fls. 211-3) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu Anderson declarou que estava no local para comprar uma porção de drogas, quando foi abordado pelos guardas municipais. Afirmou que trazia consigo apenas uma (sic) "bagana de maconha". Alegou ter corrido quando o olheiro gritou, pois temia ser confundido com o vendedor. Acrescentou que os agentes municipais detiveram, junto com ele, o adolescente que vendia as drogas e o olheiro. Negou estar com a bolsa (fl. 13).

Em juízo, afirmou que estava no local comprando drogas de uma pessoa que aparentava ser menor de idade. Não conhece Cláudio e não o viu no local (mídia digital).

De forma diversa, o réu Cláudio, na fase administrativa, afirmou que, pela manhã, foi até o local comprar maconha, porém, como não tinha dinheiro, uma garota sugeriu que atuasse como olheiro e ao final do dia receberia o entorpecente, o que foi feito. Viu que as pessoas se deslocavam até dois rapazes e compravam drogas deles. Em dado momento, viu os integrantes da guarda civil municipal e gritou. Tentou correr, porém foi detido (fl. 21).

Sob o contraditório, inovou. Alegou que estava no local com uma moça, quando uma pessoa gritou (sic) "moiô" e todos correram. Anderson estava na companhia de um menor, vendendo entorpecentes. Sabe disso, pois referida mulher contou. Na sequência, ouviu um barulho de tiro e correu. Não viu o Anderson vendendo, porém soube que ele estava na companhia do menor. Nunca viu o corréu antes (mídia digital).

A versão dos réus, contraditórias entre si e com aquelas prestadas perante à d. Autoridade Policial, não merecem credibilidade.

Os guardas municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) "foi efetuada diligência ao local dos fatos em razão de já ter sido surpreendida ali a prática de venda de drogas em datas anteriores. Assim que o condutor chegou à via pública, um

homem correu e gritou que policiais estavam chegando, momento em que foi visto um segundo suspeito jogar no solo uma bolsa que levava com ele, sendo que havia um adolescente, próximo a este segundo suspeito. Os três suspeitos correram, mas acabaram sendo detidos. O primeiro suspeito, que gritou avisando da chegada da equipe da GCM foi identificado como sendo Cláudio e trazia consigo um telefone celular, que se verificou ser produto de roubo, fato ocorrido na data de ontem, objeto que afirmou ter comprado das mãos de um desconhecido, pela quantia de cem reais, na noite de ontem, sendo que confessou que, no momento em que a equipe da GCM chegou ali, estava pelo local dos fatos para avisar acerca da chegada de policiais para as pessoas que vendiam drogas e disse que sabia que as drogas eram compradas próximo de onde estavam os outros dois rapazes abordados, mas que não sabia quem dos dois estava com a bolsa e efetuava a venda. O suspeito que foi visto jogando a bolsa no solo foi identificado como sendo Anderson, enquanto que o adolescente que havia corrido junto a este foi identificado como sendo Luan. A bolsa que Anderson jogou no solo ao ver a chegada da equipe da GCM continha 55 porções do que parecia ser cocaína, 61 porções do que parecia ser "crack" e 24 porções do que parecia ser maconha, além de R\$ 74,00, em dinheiro" (fls. 9-11).

Durante a instrução, o guarda municipal Rafael confirmou a dinâmica dos fatos. Afirmou que Cláudio foi quem anunciou a chegada da equipe e Anderson estava com a bolsa com as drogas, próximo a um adolescente. Disse, ainda, que Anderson estava conversando com o menor e, após os gritos do corréu Cláudio, dispensou a bolsa com as drogas (mídia digital).

O agente municipal Leonardo, por sua vez, afirmou que devido ao tempo transcorrido e ao número de operações similares realizadas no mesmo local, não se recordava de detalhes do ocorrido. Narrou ter sido o responsável pela prisão de Cláudio, que estava com os pertences do tráfico. Não se recordou da participação do réu Anderson, nem quantas pessoas foram abordadas naquela data. Segundo ele, Cláudio estava portando uma sacola, com papel, caneta e drogas. Não soube dizer se alguém avisou a chegada da polícia (mídia digital).

Ao final da instrução, de rigor a condenação.

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelo GCM Rafael, além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a Autoridade Policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivesse motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

Embora o agente municipal, num primeiro momento, não tenha se recordado da função dos acusados, pelas suas fisionomias, o que é compreensível em razão do tempo transcorrido desde a data dos fatos, fato é que confirmou integralmente a dinâmica dos fatos e esclareceu a atuação de cada um dos réus, indicando que Cláudio era o olheiro e Anderson, o "vapor".

Além disso, o fato de o GCM Leonardo não se recordar da ocorrência não infirma a prova acusativa. Note-se que ao ser questionado sobre a ocorrência, o agente dede logo afirmou a impossibilidade de recordar sobre detalhes, diante das inúmeras diligências símiles realizadas no mesmo local e do decurso do tempo.

Acrescente-se que o adolescente detido declarou, na fase inquisitiva, que (sic) "foi ao local dos fatos para comprar uma porção de maconha, sendo que o rapaz que efetuava a venda pediu para que o adolescente ficasse ali com ele um tempo. Ficou no local conversando com o rapaz que efetuava a venda de drogas durante a tarde, mas informa que não fez parte de qualquer ato de comércio, só observando as pessoas que iam até ali comprar as substâncias. Uma equipe da GCM chegou ao local e o "olheiro", que estava próximo a eles gritou que havia policiais ali" (fl. 12).

Em contrapartida, os réus apresentaram declarações contraditórias, a indicar que

falsearam a verdade.

No mais, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que os réus atuavam em comparsaria para o narcotráfico.

Não se amolda, ao caso em tela, notadamente a conduta do réu Cláudio, o disposto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que não há prova da existência de grupo, organização ou associação para o tráfico de drogas para o qual o réu pudesse estar colaborando, ao contrário, participou de forma determinante, para o êxito do tráfico de drogas. Nesse sentido:

Interpretando-se sistematicamente a nova legislação, verifica-se que, apesar de não haver disposição específica acerca da conduta, a função de garantir a realização de qualquer dos atos descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, concorre para que elas se concretizem, não sendo razoável, portanto, falar-se em descriminalização do exercício de atividade de segurança, de 'fogueteiro', ou de 'olheiro' do tráfico de drogas. (STJ, HC 144.086/RJ)

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Apesar disso, como bem observado pelas partes, em que pese a denúncia mencionar a participação do adolescente na prática do delito, tal circunstância não restou suficientemente comprovada sob o contraditório. Assim, afasta-se a causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base dos réus 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas – 55 porções de cocaína (41g), 61 de crack (12,1g) e 24 de maconha (31,6g), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

“A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios.” (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade relativa ao réu Anderson, a pena retorna ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A pena do

réu Cláudio permanece inalterada.

Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias do delito - réus presos em flagrante, com significativa quantidade e variedade de entorpecentes, atuando em comparsaria, em local conhecido como ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas, bem como a falta de comprovação do exercício de atividade lícita-, parece-me claro o acentuado envolvimento dos acusados no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

Acrescento que, durante a instrução, o réu Anderson afirmou já ter sido apreendido pela prática do crime de tráfico (mídia digital - 11min53seg), o que evidencia, ainda mais, sua dedicação às atividades criminosas.

Nessa direção:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-

2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabilizam-se, assim, as sanções em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o réu Anderson e 05 anos e 10 meses de reclusão de 583 dias-multa para o réu Cláudio.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu ANDERSON MARCELO LEITE GARCIA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu CLÁUDIO RODRIGUES DE FREITAS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no unitário mínimo, ambos por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, afastando-se a incidência da causa de aumento do inciso IV do artigo 40 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao réu Cláudio o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

De outro lado, faculta-se o apelo do réu Anderson em liberdade, tendo em vista que respondeu solto ao feito.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e do estojo apreendido, bem como decreto o perdimento dos valores, em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA